

Take Home Exam: Direito da Publicidade e Propriedade Intelectual – 2025/2026

1. Na sua opinião, este anúncio às carteiras **Miu Miu** é lícito? Justifique a resposta. O que poderá acontecer caso seja considerado ilícito? Esta fotografia publicitária pode ser protegida por direitos de autor? Na hipótese afirmativa, quem seriam os titulares dos direitos de autor sobre a mesma, supondo que foi criada por um fotógrafo por encomenda de uma agência publicitária portuguesa contratada para esta campanha publicitária.



R: O anúncio em apreço retrata uma modelo de aparência muito juvenil, sentada sobre os carris de uma linha de comboios, com uma expressão melancólica, segurando uma carteira da marca Miu Miu. Creio que a ideia seja passar uma estética de *enfants riches déprimés*, uma *coutoure* nihilista associada à marca, que desenvolveremos adiante.

A imagem é destinada a promover, junto do público, a comercialização das referidas carteiras, integrando-se assim no conceito de publicidade o art. 3.º, n.º 1, al. a) do DL n.º 330/90, de 23 de Outubro (Código da Publicidade, “CP”). Sendo uma comunicação comercial difundida em Portugal (hipótese), aplicam-se cumulativamente o CP, o DL n.º 57/2008, de 26 de Março ([Regime Jurídico das] Práticas Comerciais Desleais, “RJPCD”) e, em sede auto-regulatória, o Código de Conduta da ARP (Associação da Auto Regulação Publicitária)

E: Na sua opinião, este anúncio às carteiras Miu Miu é ilícito?

R: Nos termos do art. 60.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa (“CRP”), “a publicidade é disciplinada por lei¹ (...)”. O art. 6.º do CP preceitua que a publicidade “rege-se pelos princípios da licitude, identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor”. No anúncio em concreto, está em causa o princípio da licitude (art. 7.º CP), e os deveres especiais consagrados nos artigos 13.º CP (saúde e segurança do consumidor) e 14.º CP (menores)

O art. 7.º, n.º 1 do CP proíbe a publicidade que ofenda “valores (...) constitucionalmente consagrados. Em particular, o art. 7.º, n.º 2, al. c) CP veda a publicidade que “atente contra a dignidade da pessoa humana”.

Obviamente, a aparente juventude da modelo, *per se*, não viola este preceito; mas, a sua representação, numa pose passiva, com o olhar abatido, sentada sob os carris de uma linha de comboio, evoca uma estética de vulnerabilidade, de ideação suicida. Entendemos que há uma instrumentalização da figura humana como mero suporte estético do produto, em condições limítrofes da dignidade. Fala-se, a este propósito, que a invocação do princípio da dignidade abrange, neste contexto, os casos em que a mensagem coisifica o ser humano ou explora a sua fragilidade. O art. 13.º, n.º 1 do CP proíbe a publicidade que “encoraje comportamentos prejudiciais à saúde² e segurança do consumidor (...)” (e, no n.º 2, “a publicidade não deve comportar qualquer apresentação visual ou descrição de situações onde a segurança não seja respeitada, salvo justificação de ordem pedagógica”. Ora, sentar-se sobre os carris de uma linha de ferro é, por natureza, um comportamento perigoso, e, *in casu*, sem qualquer fim pedagógico (a finalidade é puramente comercial). A imagem “normaliza”, *glamoriza* e *estetiza* a o vazio de uma juventude que tem acesso a tudo (a Miu Miu é uma *griffe*....) mas não encontra sentido em nada, através da permanência sobre a via-férrea, comportamento que está na origem de inúmeros acidentes mortais. Verifica-se, portanto, uma clara violação do art. 13.º, n.º 2 do CP.

¹ Sendo a publicidade um meio potente de promover o consumo e influenciar o consumidor, compreende-se que a Constituição tenha privilegiado o seu tratamento, determinado a sua disciplina por via legal (reserva de lei reguladora), e proibindo directamente, desde logo, certas formas de publicidade, em homenagem ao princípio de que ela tem de ser pelo menos *identificável como tal* pelos consumidores e *verdadeira*. Em todo o caso, a publicidade de bens e serviços, para além de ter assento constitucional, enquanto componente da liberdade económica e da concorrência numa economia de mercado (liberdade de publicidade) [ainda que com restrições], constituem também um mecanismo de informação dos consumidores e de promoção da sua liberdade de escolha.

² **Obiter dicta**, incluímos aqui a saúde mental? Entendemos que sim.

O n.º 3 do art. 13.º do CP exige que “deve ser particularmente acautelado no caso da publicidade especialmente dirigida a criança, adolescentes (...)”. Ora, a Miu Miu é frequentemente descrita como a “irmã mais nova”³ da Prada, voltada para um público mais jovem, tipicamente feminino jovem (ou seja, adolescentes), o que agrava a censura.

Importa distinguir entre publicidade dirigida a menores e publicidade que utiliza menores como intervenientes/instrumentos. Nos dois planos, a mensagem publicitária suscita reservas: (i) como destinatário, o público preferencial deste tipo de campanhas inclui adolescentes (“menores”) e jovens adultos. O art 14.º, n.º 1, al. c) do CP proíbe que a publicidade dirigida a menores contenha “elementos susceptíveis de fazerem perigar a sua integridade física ou moral, bem como a sua saúde ou segurança”. A representação de uma jovem na via-férrea é, sem mais, idónea a sugerir um comportamento perigoso passível de imitação; (ii) como protagonista (instrumentalização), se a modelo retratada for, de facto, menor então acresce a violação do art. 14.º, n.º 2 CP, segundo o qual “os menores só podem ser intervenientes principais nas mensagens publicitárias em que se verifique existir uma relação directa entre eles e o produto ou serviço veiculado”. O produto é dirigido a um público, jovem, mas adolescente/adulto, com elevada capacidade económica, podendo até incluir menores, mas não há uma “relação directa” – ou, a existir, refere-se aos adolescentes, ainda menores.

O Código de Conduta da ARP estabelece, nos seus princípios gerais, deveres de Decência (art. 6.º), Responsabilidade Social (art. 8.º) e protecção especial de Crianças e jovens (artigo 22.º), destacando o n.º 2 do art. 22.º, “um cuidado particular deve ser tido nas Comunicações Comerciais (...) veiculadas por crianças ou jovens. Tais comunicações não podem comprometer, desvalorizar, subestimar nem prejudicar a actividade, o comportamento social e o *estilo de vida positivos*” (itálico nosso). A *negatividade* inerente da mensagem publicitária da Miu Miu, projectado para um público jovem e veiculado por uma modelo jovem, é contrário à *soft law*.

Concluimos, portanto, que este anúncio é ilícito, por violação dos arts. 7.º, n.º 2, al. c), 13.º, n.º 1 e n.º 2 e 14.º, n.º 1 c) e/ou 14.º, n.º 2, todos do CP, sem prejuízo da censura paralela ao abrigo do Código de Conduta da ARP.

E: O que poderá acontecer caso seja considerado ilícito?

³ Vide <https://blog.etiquetaunica.com.br/web-stories/miu-miu-a-irma-mais-nova-da-prada/>

R: No tocante às consequências da ilicitude, começando pelo plano contraordenacional: a violação dos artigos do CP referidos *supra*, ainda que negligentemente (*ex vi* 34.º, n.º 2 CP) é cominada, no artigo 34.º, n.º 1 al. a) do CP, com coima de € 1.750 a € 3.750 (pessoa singular) ou de € 3.500 a € 45.000 (pessoa colectiva). Podem ainda ser aplicadas as sanções acessórias previstas nas alíneas do n.º 1 art. 35.º CP: *in casu*, relevariam mais a al. b) “Interdição temporária, até um máximo de dois anos, de exercer a actividade publicitária”, a al. c) “Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou serviços públicos” e a al. d) “Encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos onde se verifique o exercício da actividade publicitária” (caso, p.ex., a imagem da mensagem publicitária se encontre nas lojas da Miu Miu).

Nos termos do art. 36.º do CP, são responsáveis o anunciante (Miu Miu), a agência de publicidade (a “agência publicitária portuguesa contratada para esta campanha publicitária” como resulta do enunciado), o titular do suporte “bem como qualquer outro interveniente na emissão da mensagem publicitária”. Nos termos conjugados dos artigos 37.º, 38.º e 40.º do CP, a fiscalização e a instrução dos processos e compete especialmente à Direção Geral do Consumidor (DGC) (cujo antecessor é a o Instituto do Consumidor que a lei refere).

Nos termos do art. 41.º, n.º 1 do CP, “em caso de publicidade (...) que, pelo seu objecto, forma ou fim, acarrete ou possa acarretar riscos para a saúde, a segurança, os direitos ou interesses legalmente protegidos dos seus destinatários, de menores ou do público” a “entidade competente” pode ordenar “independentemente de culpa ou da prova de uma perda ou de um prejuízo real” medidas cautelares de suspensão, cessação ou proibição daquela publicidade, até por 60 dias (41.º, n.º 5 CP), podendo ainda determinar a difusão de publicidade correctora a expensas do infractor (art. 41.º, n.º 7 do CP) e a publicitação do acto que aplique a medida cautelar.

Já no plano da responsabilidade civil aquiliana, prevista no art. 30.º do CP, “os anunciantes (...) as agências de publicidade (...) bem como os titulares dos suportes publicitários utilizados (...) respondem civil e solidariamente, nos termos gerais, pelos prejuízos causados a terceiros em resultado da difusão de mensagens publicitárias ilícitas”, sendo que o CP estabelece que o anunciante eximir-se-á se provar não ter tido conhecimento prévio da mensagem (artigo 30.º, n.º 2 do CP), defesa difícil de invocar quando se trata de um anúncio da própria anunciante, Miu Miu. Não obstante a manifesta ilicitude do facto, a responsabilidade civil, para operar, exige ainda que se prove, nos termos dos art. 483.º e seguintes do Código Civil (“CCiv”), um dano em concreto e correspondente nexo de causalidade com o facto ilícito, questão mais espinhosa, tendo

em conta a mera *sugestibilidade* da mensagem publicitária – entenda-se, poder-se-á dizer que determinado dano ocorreu, *por causa*, desta imagem, *per se*? Tudo dependerá das circunstâncias casuísticas.

E: Esta fotografia publicitária pode ser protegida por direitos de autor?

R: Nos termos do art. 1.º/1 e art. 2.º do DL n.º 63/85 (Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos “CDADC”), são obras protegidas as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, que sejam originais, sendo, nos termos do art. 1.º, n.º 3, a obra independente da sua divulgação, publicação, utilização ou exploração (a finalidade publicitária é, pois, irrelevante para a qualificação como obra; *vide*, também, o art. 29.º, n.º 1 do CP que estabelece que “as disposições legais sobre direitos de autor aplicam-se à criação publicitária (...)”

A enumeração do art. 2.º, n.º 1 do CDADC é meramente exemplificativa ([...] compreendem *nomeadamente* [itálico nosso]), todavia, inclui, na al. h) as obras fotográficas. Tratando-se de obra fotográfica, a tutela depende, nos termos do art. 164.º, n.º 1 do CDADC, de a obra poder considerar-se, “pela escolha do seu objecto ou pelas condições da sua execução” como “criação artística pessoal do seu autor”, excluindo, portanto, as fotografias meramente reprodutivas de “escritos, de documentos, de papéis de negócios, de desenhos técnicos e de coisas semelhantes” (art. 164.º, n.º 2 do CDADC)⁴.

No que diz respeito a saber se uma fotografia beneficia da protecção dos direitos de autor, o TJUE, no acórdão C-05/08 *Infopaq*, interpretou o art. 6.º da Diretiva 93/98 no sentido em que o direito de autor só é susceptível de se aplicar a um objecto, como uma fotografia, que seja original, na acepção de que é uma Criação Intelectual Própria do Autor (CIPA) e que uma criação intelectual é própria do respectivo autor, quando reflecte a sua personalidade. Ora, é esse o caso quando o autor pode exprimir as suas actividades criativas na realização da obra, fazendo escolhas livres e criativas (*a contrario*, C-403/08 *Football Association Premier League* e C-429/08 *Collect*)

No que diz respeito a uma fotografia, há que observar que o autor poderá efectuar as suas escolhas livres e criativas, de diversas maneiras e em diferentes momentos da sua realização. “No estádio da fase preparatória, o autor poderá escolher o pano de fundo, a pose da pessoa a fotografar ou a iluminação. No momento em que tira o retrato fotográfico, poderá escolher o enquadramento, o ângulo de que deve ser tirado ou ainda

⁴ *Vide* C-604/10 *Football Dataco* onde se interpretou que listas de jogos de futebol não são originais, pois eram resultado de regras técnicas e não de escolhas criativas.

a atmosfera criada. (...) Através dessas diferentes escolhas, o autor de um retrato fotográfico pode, assim, imprimir o seu “toque pessoal” à obra criada”⁵

Sendo a “originalidade” de uma obra um conceito de Direito, como revela desde logo a jurisprudência do TJUE, o juízo jurídico da originalidade assentará, não em critérios dos domínios literários, científicos ou artísticos, mas em critérios próprios do domínio jurídico. Os requisitos jurídicos de originalidade adiantados pelo TJ, consiste no conceito de CIPA, e no requisito de o material ser expresso com suficiente precisão e objectividade⁶. Sendo “necessário e suficiente” para verificar-se a “originalidade”, que o resultado material da “obra”, reflecta a personalidade do seu autor, manifestando escolhas livres e criativas deste (CIPA).

Assim sendo, *in casu*, não há dúvidas que a fotografia publicitária pode ser protegida por direitos de autor: o fotógrafo escolheu o cenário (a linha de comboios), o enquadramento (plano picado, ligeiramente lateral), a luz natural, a paleta cromática (tons terrosos e quentes em contraste com o cinza dos carris), o *styling*, a pose e a expressão da modelo, a profundidade do campo (o “desfoque” do fundo para destacar o sujeito, efeito denominado de *bokeh*); a fotografia incorpora, pois, escolhas livres e criativas suficientes para preencher o critério de CIPA (reclamado também pelo TJUE, no C-683 *Cofemel* e, mais recentemente, C-580/23/C-795/23, *Mio v. Galleri Mikael e USM v. konektra*)

Conclui-se assim que a fotografia publicitária é protegida por direito de autor enquanto obra fotográfica.

⁵ C-145/10 *Eva Marie Painer*, § 91 e 92. E ainda, “Face ao que antecede (...), há, portanto, que considerar que um retrato fotográfico é susceptível (...) de ser protegido por direitos de autor, desde que (...) sendo uma criação intelectual do autor, que reflecte a sua personalidade e se manifesta pelas suas escolhas livres e criativas durante a realização dessa fotografia” *cit.*, § 94.

⁶ O que explica que obras culinárias não possam ser qualificadas como obras originais, pois o sabor dos alimentos é demasiado *subjetivo*, variável e impossível de ser fixado ou descrito de forma *objectiva e precisa*. C-310/17 *Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV*. Assim sendo, para ser protegida, uma obra deve poder ser identificada com *precisão e objectividade*.

E: Na hipótese afirmativa, quem seriam os titulares dos direitos de autor sobre a mesma, supondo que foi criada por um fotógrafo por encomenda de uma agência publicitária portuguesa contratada para esta campanha publicitária.

R: O direito de autor nasce automaticamente com a criação⁷ da obra⁸, independentemente de qualquer formalidade, tem um carácter dual: *i.e.*, desdobra-se em duas ordens (*ex vi* art. 9.º, n.º 1 CDADC), direitos pessoais (ou morais) e direitos patrimoniais. Neste dualismo reflecte-se o facto de a obra ser simultaneamente um bem susceptível de constituir objecto de transacções económicas e a expressão da personalidade do autor, tributário do sistema personalista, continental do Direito de Autor, cuja nossa tradição jurídica herdou das leis francesas do final do séc. XVIII redigidas por LE CHAPELIER⁹ (*droit d'auteur*).

Os direitos patrimoniais de autor correspondem ao conteúdo económico-patrimonial do direito de autor (art. 9.º, n.º 2 CDADC). Conferem ao autor o direito exclusivo de dispor da obra, de a fruir e utilizar, ou de autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente (art. 67.º, n.º 1 CDADC), em qualquer das modalidades de utilização possíveis “actualmente conhecidas ou que de futuro o venham a ser”, designadamente publicação, edição, reprodução, distribuição, tradução, adaptação, comunicação ao público (art. 68.º CDADC). A garantia das vantagens patrimoniais resultantes da exploração da obra constitui “o objecto fundamental da protecção legal” (art. 67.º, n.º 2 CDADC). São alienáveis (transmissíveis *inter vivos* ou *mortis causa*), transmissíveis e oneráveis, “no todo ou em parte” (susceptíveis de cessão, licença, penhor, arts. 40.º e segs. CDADC) e prescritíveis, caducando, em regra, 70 anos *post mortem auctoris* (art. 31.º CDADC)

Os direitos morais (ou pessoais) de autor, corresponde ao conteúdo pessoal do direito de autor, reflexo da relação umbilical entre o autor e a sua obra enquanto projecção da sua personalidade. Compreendem, independentemente dos direitos

⁷ “Definimos criação como o acto de exteriorização formal de uma obra intelectual”, *cit.*, ALBERTO SÁ E MELLO, Manual..., *op. cit.*, p. 76.

⁸ “É, pois, certo que a constituição da situação jurídica do direito de autor pela exteriorização da obra não depende da vontade do seu autor-criador, pelo que o efeito jurídico desta acção é independente da vontade do sujeito; e, neste sentido, é mero facto jurídico.”, *cit.*, ALBERTO SÁ E MELLO, Manual..., *op. cit.*, p. 77.

⁹ LE CHAPELIER, relator da *Loi du 13 janvier 1791 Relative aux Spectacles*, declarou perante L’Assemblée Nationale que “La plus sacrée, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain”. É uma forma totalmente diferente de pensar o direito de autor vs. a concepção do *copyright* uma vez que tem como postulado que o direito de autor é um *direito de propriedade* com *carácter sacramental*, ao contrário da visão anglo-saxónica que é muito mais “*society-focused*” entendendo este como um “mero” monopólio legal, um exclusivo atribuído por lei, cuja finalidade é a promoção da criação literária, artística e científica. Consequentemente, o *droit d'auteur* nasce com a criação da obra – não através da lei (como na *common law*); no sistema continental o Direito limita-se a *reconhecer* a obra.

patrimoniais, o direito de reivindicar a paternidade da obra e o direito de assegurar a sua genuinidade e integridade, opondo-se à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra modificação, e, de um modo geral, a todo o acto que desvirtue e possa afectar a honra e reputação do autor (arts. 9.º, n.º 3 e 56.º, n.º 1 CDADC). Estas faculdades são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, perpetuando-se após a morte do autor (art. 56.º, n.º 2 CDADC¹⁰)

A “actividade publicitária” compreende, nos termos da lei, “o conjunto de operações relacionadas com a difusão de uma mensagem publicitária, incluindo as relações (...) daí emergentes entre anunciantes, profissionais, agências de publicidade e entidades que explorem os suportes publicitários” (art. 4.º, n.º 1 CP).

Para completar o quadro das noções legais deve acrescentar-se que a “publicidade” é designada como “qualquer forma de comunicação feita por entidades (...) no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo de promover bens, serviços, ideias, princípios, iniciativas ou instituições” (art. 3.º, n.º 1 CP). Detemo-nos a considerar que, para o regime do CP, a publicidade é fundamentalmente encarada como uma actividade empresarial – ainda que desenvolvida por pessoas singulares, uma vez que a parece prever apenas o seu exercício “profissional” – logo, propícia ao enquadramento como “**criações (funcionais) para uma organização/empresa**”. Por outro lado, a multifacetada natureza dos meios que veiculam os objectos publicitários deixa antever a possibilidade de compreender uma pluralidade de *objectos criativos* (*in casu*, os diferentes elementos da fotografia, entenda-se, a própria *ideia visual da peça*¹¹ [uma jovem sentada sobre carris, em estado de vulnerabilidade é um contributo de *creative direction*, do fotógrafo e/ou da agência]; as “escolhas livres e criativas” quanto ao enquadramento, iluminação, por parte do fotógrafo; o conjunto vestido pela modelo resultado de uma escolha por um *stylist* da agência¹², etc.) pelo que os requisitos de protecção das prováveis “obras publicitárias” são comuns a praticamente *todos e cada um* dos géneros previstos no art. 2.º do CDADC¹³.

¹⁰ Com regime de exercício *post mortem* nos termos do art. 57.º CDADC.

¹¹ Não é objecto autonomamente protegível enquanto *mera ideia* (cfr. art. 1.º, n.º 2 CDADC) mas materializa-se na peça.

¹² Se o conjunto formar uma criação estética original, pode constituir contributo autonomamente protegível (cfr. art. 2.º, n.º 1 al. i) CDADC)

¹³ A profusão de noções a que o CP recorre, recomenda, ainda que apenas para efeitos da presente exposição, que se fixe terminologia que sirva instrumento de trabalho. Assim:

- i. *Publicidade*: é o conjunto de actividades que tem por fim promover comercialmente bens ou serviços, assim como (a promoção) de ideias, princípios, iniciativas ou instituições – nossa análise do art. 3.º, n.º 1 do CP.

Define-se depois “anunciante”, “a pessoa singular ou colectiva o interesse de quem se realiza a publicidade” (art. 5.º, al. a) CP) e “profissional ou agência de publicidade”, “a pessoa singular que exerce a actividade publicitária ou a pessoa colectiva que tenha por objecto exclusivo o exercício da actividade publicitária” (art. 5.º, al. b) CP).

À primeira vista, será entre estes sujeitos que se estruturarão as situações jurídicas com relevância na atribuição de direitos de autor: os *anunciantes*, como comitentes, contratam a criação publicitária¹⁴; as *agências de publicidade* enquadram essa criação. Por outro lado, no que à atribuição do direito de autor respeita, interessarão também as relações entre *agências de publicidade* e os criadores (individuais) da “mensagem publicitária” (mais pertinentemente para o caso, o fotógrafo) – que a lei nunca define, embora os mencione de forma incidental, como veremos.

Importa realçar que a prática da actividade das agências de publicidade mostra que as campanhas publicitárias são resultado dos contributos intelectuais diferenciados de duas categorias de colaboradores dessas agências: os que pertencem aos seus quadros, e são remunerados mensalmente; e os que não pertencem aos seus quadros e trabalham por encomenda (no caso em apreço, o fotógrafo)

-
- ii. *Actividade publicitária*: é o conjunto de actos na origem ed situações jurídicas que estabelecem as relações entre os *anunciantes*, os *profissionais/agentes de publicidade* e *entidades titulares de suportes* e de *veículos publicitários* (cfr. arts. 4.º, n.º 1 e 5.º b) e c) do CP)
 - iii. *Objecto publicitário*: é todo o objecto jurídico apto à fixação ou difusão de publicidade, incluindo as próprias *mensagens publicitárias* (criativas ou não) que incorporem;
 - iv. *Suporte publicitário*: o *corpus mechanicum* que fixa a “mensagem publicitária” (papel, película fotográfica, suporte digital) sem que acompanhem a equívoca equivalência “*suporte publicitário/veículo, publicitário*” a que recorre a definição legal do art. 5.º, c) do CP.
 - v. *Veículo publicitário* – o meio através do qual a mensagem publicitária é difundida (imprensa escrita, rádio, televisão, Internet, “placard”, serviço de telecomunicações postais ou telefónicas, etc.).
 - vi. *Mensagem publicitária*: o objecto jurídico da *actividade publicitária* que, se for *original*, no sentido de que é uma *criação intelectual própria do respectivo autor*, por *reflectir a sua personalidade* através de escolhas *livres e criativas*, de maneira suficientemente *precisa e objectiva*, na sua realização, é uma *obra intelectual* com protecção jusautorais, a que chamaremos *obra publicitária*.

¹⁴ O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 7/7/1999, reproduzido pela ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL “CASA DO JUIZ”, Colectânea de Jurisprudência – Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano VII – 1999, Tomo III, Coimbra, pp. 23 e segs. (máxime, p. 24) que tem como Relator: Fernandes de Magalhães, aprecia incidentalmente a posição jurídica do *anunciante* no fenómeno jurídico publicitário e considera, a propósito da responsabilidade civil deste sujeito por mensagens publicitárias ilícitas: “(...) há que ter em conta o aludido no art. 30.º [do CP] estabelece tão-só como facto gerador da responsabilidade típica no âmbito da actividade publicitária apenas a difusão de mensagens publicitárias que sejam em si mesmas ilícitas, (...)” E continua, *ibidem*, agora no que mais nos interessa, “Nesta perspectiva e tão somente nela, se compreende que a lei a todos responsabilize solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros pela mensagem publicitária ilícita e mesmo aí estabelece uma distinção: reconhece que o anunciante é um elemento exterior ao processo publicitário (...)”

O art. 29.º, n.º 2 CP estatui que “os direitos de carácter patrimonial presumem-se, salvo convenção em contrário, cedidos em exclusivo ao seu criador intelectual”

Evidentemente, esta formulação do art. 29.º, n.º 2 do CP nada esclarece quanto ao regime das situações jusautorais constituídas a partir da criação de obras publicitárias em execução de contrato, considerado o absurdo que representa dizer “cedida uma posição de exclusivo (patrimonial jusautorai)” a quem – o criador intelectual da obra - a ocupa por condição natural¹⁵. Ou seja, se o autor da mensagem publicitária, uma obra intelectual, é o *titular originário* do direito de autor sobre esta, que sentido faz presumir “ceder-lhe” esse direito?

Tentaremos, apesar da fórmula legal portuguesa, determinar a *fonte* da atribuição dos direitos de autor nas obras publicitárias.

Centramos a nossa atenção na situação jurídica que emerge do contrato celebrado *entre o anunciante e a agência de publicidade*, que tem como objecto a criação da mensagem (*criativa*) publicitária. Vimos já que, reunidos os pressupostos requeridos, esta pode constituir *obra intelectual*.

A criação publicitária – entenda-se, a *exteriorização formal da mensagem publicitária criativa*, uma vez que a mera “*idealização e concepção*” não são, por si só e nos termos gerais do Direito de Autor, merecedoras de tutela jusautorai¹⁶.

Resulta normalmente de um contrato oneroso, celebrado entre um anunciante e uma dita *agência de publicidade*, que parece constituir um feixe de deveres semelhantes aos que vamos caracterizar o que chamamos ***criação funcional***¹⁷. Se tal se confirmar, confrontamos uma criação em cumprimento de uma obrigação que tem como efeito a

¹⁵ Releva-o bem o Acórdão da Relação de Lisboa, de 3/11/1999, *In ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL “CASA DO JUIZ”, Colectânea de Jurisprudência - Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano VII – 1999, Tomo V, Coimbra, pp. 136 e segs. (máxime, p. 137), que tem como relatora Ana Moreira da Silva, em apreciação da atribuição da titularidade originária do direito de autor em pretensa obra publicitária ficada em videograma ao considerar “É certo que também o art. 29.º, n.º 2 do DL n.º 330/90, de 23-10 ([versão anterior do] Código da Publicidade), consagrou idêntica solução [a atribuição da titularidade do direito de autor, sob o aspecto patrimonial, “determinada em função do acordo celebrado entre criador e a entidade que encomenda a obra ou por conta de quem ela é feita” – como pode ler-se em outra passagem da mesma douda decisão], muito embora consagrando uma aquisição derivada do criador intelectual, ao estipular que “os direitos de carácter patrimonial sobre a criação publicitária presumem-se, salvo convenção em contrário, cedidos em exclusivo ao seu criador intelectual”. Com efeito, aqui parece que se queria beneficiar a empresa de publicidade na exploração sem peias da obra publicitária, mas veio a legislar-se o contrário, pelo que o **preceito não tem qualquer sentido útil face ao Direito de Autor**, nomeadamente no que se preceitua nos arts. 14.º e 15.º do CDADC” (realce e negrito nosso)*

¹⁶ Princípio insito na lei portuguesa no art. 1.º, n.º 2 do CDADC.

¹⁷ Designação adoptada por ALBERTO SÁ E MELLO, Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos, 6.ª ed., Almedina, Coimbra, 2025, pp. 491-494

atribuição de faculdades de direito de autor conforme aos fins da utilização da obra por outrem, neste caso, o *anunciante*.

À primeira vista, dir-se-ia não encontrarmos aqui, no que à caracterização dos actos que *atribuem originariamente faculdades jusautorais* respeita – qualquer novidade no universo das *obras criadas por outrem em execução de contrato*. Sem estranheza, o direito de autor na obra (dita, “mensagem”) publicitária constituir-se-ia segundo as regras para a atribuição convencional de faculdades de utilização da obra ao comitente enquanto criador intelectual (art. 11.º CDADC): ou originariamente “atribuída” (art. 19.º CDADC) na titularidade *da entidade* – pessoa singular ou criativa – que empreendesse e organizasse a criação.

É, porém, relevante que se trate aqui de uma **criação funcional**, neste caso **vinculada aos fins** aquele que contrata a actividade/prestação criativa publicitária, o **anunciante**. Assim,

- 1) A criação da obra publicitária pode ser realizada **no âmbito de contrato com esse objecto, celebrado directamente entre o anunciante e um ou mais criadores**¹⁸ - que, do que resulta do enunciado, não é o caso (a Miu Miu contratou a agência publicitária portuguesa que, por sua vez, encomendou a fotografia publicitária a um fotógrafo)
- 2) **Se a obra publicitária for criada sob égide da “agência de publicidade”,** é susceptível de ser caracterizada como **obra colectiva**, desde que o respectivo processo criativo revista as características antes assinaladas. Nesta poderão combinar-se *dois feixes* de situações de direito de autor:
 - i) O que resulta da **vinculação de cada um dos autores de contributos criativos individuais à “agência de publicidade”** (em especial, *in casu*, o fotógrafo), que segue as *regras gerais para a atribuição de faculdades jusautorais em obras discrimináveis para utilização em obra colectiva* (a obra/ “mensagem publicitária” considerada no seu conjunto). Neste caso, a exploração económica *destes contributos individuais quanto a outras utilizações pelos respectivos autores*, está limitada também, nos termos que definiremos *infra*, *em geral*, para a utilização “*em separado*” de obras integradas em obra colectiva.
 - ii) Um outro que nasce da **vinculação da “agência de publicidade” ao anunciante**, que **obriga a agência a criar a obra publicitária para fins de**

¹⁸ Nada impede que o anunciante contrate directamente os *criativos publicitários* que assim poderão criar em autoria singular ou em colaboração. Verificar-se-ia neste caso a atribuição do direito de autor, ora *ao(s) criador(es)* ora ao *anunciante* (comitente ou empregador), nos termos do convencionado naquele contrato que tenha por objecto a criação dessa obra/ “mensagem” publicitária: encontramos nesse caso um exemplo de contrato para a criação de obras intelectuais (de “obra publicitária”), desde que reunidos os requisitos e nos termos *gerais*, *ex vi* art. 14.º do CDADC.

utilização deste: reger-se-á pelos princípios e regras que definimos para toda a obrigação constituída por contrato para criação de obras intelectuais. Desde que, nos termos do art. 19.º do CDADC, a “agência de publicidade” deva considerar-se titular originária (e *autora*, como sustentámos) da obra/ “mensagem publicitária” considerada no seu conjunto como obra colectiva, **a “agência” atribuirá faculdades de utilização ao anunciante para os fins convencionados**, ainda nos termos gerais. A *exploração da obra publicitária para outros fins*, quer pelo comitente anunciante quer pela “agência” titular originária do direito de autor, também estará limitada nos termos gerais que ligamos à atribuição convencional de faculdades de utilização de obras, com a particularidade de se tratar de uma **obra colectiva criada em execução de contrato**.

A “particularidade” reside, neste último caso, em que aquela empresa (a “agência publicitária” sob cuja coordenação é criada a obra publicitária) é, por sua vez, contratada para criar (pelo “anunciante”).

Por outro lado, se na obra (colectiva) publicitária puder distinguir-se uma *pluralidade de contributos* (como nos parece ser no caso *sub iudice*, o trabalho do fotógrafo e o trabalho dos colaboradores que pertencem aos quadros da agência), os respectivos criadores pessoais exercerão sobre os que forem discrimináveis da obra publicitária direitos que lhes correspondam tendo em conta o processo criativo, nos seguintes termos:

- 1) Se estiverem vinculados à “agência de publicidade” por contrato (obra feita por encomenda ou obra feita por conta de outrem¹⁹) para criação de obra intelectual (*in casu*, quanto ao fotógrafo, obra por encomenda), também se terão por atribuídos àquela agência os direitos patrimoniais da “mensagem/obra publicitária”, *desde que tal seja estipulado*, art. 14.º, n.º 1 do CDADC *ex vi* art. 29.º, n.º 1 do CP.
- 2) Se *não* estiverem vinculados à agência por *contrato que preveja a atribuição a esta de direitos sobre os seus contributos pessoais discrimináveis*, presume-se que apenas os criadores destes exercerão (individualmente ou em comunhão se os tiverem criado em colaboração) os direitos que lhes respeitem (art. 14.º, n.º 2 do CDADC, art. 29.º, n.º 2 CP) sempre com respeito do *fim* a que se destina a criação (art. 28.º CP).

¹⁹ A “obra feita por encomenda” é criada para terceiro, fora do âmbito de um contrato de trabalho ou do cumprimento de um dever funcional, enquanto a “obra feita por conta de outrem” surge no âmbito desse contrato ou em cumprimento desse dever.

- a. A particularidade reside em que, neste último caso, por força do formidável art. 29.º, n.º 2 CP, já não se presumirá, nomeadamente pela falta de menção que designa a autoria, a atribuição originária à empresa titular do direito na obra (colectiva publicitária) do direito de autor nas obras naquela incorporadas, ainda que sejam criadas em execução de contrato (afastando-se, portanto, o regime do art. 14.º, n.º 3 CDADC)
- b. Está, por outro lado, excluída *qualquer* utilização “*em separado*” desses contributos pela empresa – entenda-se *qualquer utilização para fins diversos dos da incorporação na obra*” “*mensagem publicitária*” -, salvo quando esta esteja convencionada (art. 28.º CP, “é proibida a utilização para fins diferentes dos acordados (...) material publicitário fornecido para fins contratuais relacionados com alguma das operações referidas no n.º 2 do artigo 4.º” [“designadamente, concepção, criação, produção, planificação e distribuição publicitárias”]) e art. 29.º, n.º 3 do CP “é ilícita a utilização de criações publicitárias sem a autorização dos titulares dos respectivos direitos”.
- c. Como se disse, já não se admitirá a derrogação do limite genérico – *ex vi*, arts. 19.º, n.º 2 e 18.º, n.º 2 do CDADC (contribuições pessoais discrimináveis) que impede qualquer utilização patrimonial dos contributos individuais com prejuízo da exploração da obra publicitária no seu todo.

Pensamos assim que o que realmente significa a fantástica cessão presumida de direitos em exclusivo ao criador intelectual, estatuída no art. 29.º, n.º 2 do CP, não justifica derrogação do regime-regra e das suas excepções conhecidas.

Se a obra publicitária for obra colectiva, cabe à empresa (a “agência de publicidade” neste caso) a titularidade originária do direito de autor na obra no seu conjunto.

Se esses contributos tiverem sido criados no âmbito de um contrato que estipule a titularidade dos direitos patrimoniais (art. 14.º, n.º 1 CDADC), pertencerão à agência de publicidade também as faculdades de utilização inerente (e limitadas) à exploração daqueles para os fins da atribuição (atribuição essa que também limita o direito destes, visto o “princípio do não prejuízo da exploração da obra colectiva” enunciado).

Aparentemente, dada a estranha formulação daquele preceito, apenas se afastarão quaisquer presunções – como a do 165.º, n.º 2²⁰ ou do art. 14.º, n.º 3 – que levam também à atribuição originária à agência de publicidade de direitos nas criações pessoais incorporadas. Por outro lado, se ao inciso “em exclusivo” do 29.º, n.º 2 do CP, quisermos dar algum conteúdo útil, já se deverá entender que fica excluída qualquer exploração *em separado pela empresa* dos contributos criativos individuais, sem que se derroque a limitação genérica que apontámos ao exercício de direitos nas obras incorporadas dada pelo “não prejuízo da exploração da obra colectiva no seu conjunto”, uma vez que tem carácter injuntivo e inutilizaria na prática a exploração da obra publicitária pela empresa.

Dir-se-á então que a peculiar disposição do art. 29.º, n.º 2 do CP também poderá ser entendida como: “Aos criadores de contributos pessoais incorporados na obra publicitária cabe, em qualquer caso, o direito exclusivo de utilização em separado das suas contribuições.”²¹ Parece ser a única formulação que permite respeitar o art. 9.º, n.º 3 do CCiv “(...), o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir os seus pensamentos em termos adequados”

Como dito *supra*, na tradição continental de inspiração do *droit d’auteur*, o direito (subjectivo) de autor abrange duas categorias fundamentais de direitos: os chamados *direitos de carácter patrimonial* e os *direitos de natureza pessoal*. Tendo já tratado exaustivamente a questão da titularidade dos direitos patrimoniais de autor, vejamos, agora, *en passant*, a titularidade dos direitos morais de autor, uma vez que esta não levanta grandes dúvidas.

Os direitos morais, como vimos, são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis. Pertencem sempre, e em qualquer caso, relativamente à fotografia, sua contribuição pessoal na obra colectiva, ao fotógrafo enquanto criador intelectual. Assim sendo, este pode reivindicar a paternidade da fotografia, e assegurar a sua “genuinidade e integridade”. Também pertencerão, nos mesmos termos, à agência publicitária direitos morais sobre a obra publicitária como um todo²².

A Miu Miu é “a pessoa (...) colectiva no interesse de quem se realiza a publicidade”, sendo, portanto, considerada como anunciante (art. 5.º, n.º 1 al. a) CP) e contratou a agência de publicidade portuguesa para conceber e executar a campanha.

²⁰ “Se a fotografia for efectuada em execução de um contrato de trabalho *ou por encomenda*, presume-se que o direito previsto neste artigo pertence à entidade patronal ou à *pessoa que fez a encomenda*”

²¹ No mesmo sentido, ALBERTO SÁ E MELLO, Manual..., *op. cit.*, p.494

²² Embora a doutrina divirja sobre a admissibilidade de direitos morais na esfera de pessoas colectivas, sustenta-se que, à agência, na qualidade de titular originária *ex vi* art. 19.º CDADC, a quem é “atribuído” o direito de autor, caberão, pelo menos, as faculdades funcionalmente equivalentes a estes – designadamente, a defesa da integridade da peça publicitária no seu conjunto.

A relação Miu Miu – agência rege-se por um contrato de criação publicitária como desenvolvemos *supra*.

O adquirente de uma criação publicitária não fica investido, em consequência da aquisição do objecto material em que os anúncios ou uma campanha publicitária se materializaram, de nenhuns direitos patrimoniais do autor. Por outras palavras, a cessão de uma obra publicitária, entenda-se, a fotografia fixada num suporte material (*corpus mechanicum*) não acarreta a cessão dos direitos sobre a mesma (*corpus mysticum*), nem sequer tal cessão se presume (art. 10.º, n.º 1 e n.º 2 CDADC). Refira-se, com relevo, uma norma *sui generis* com importância no caso em análise, que é o art. 166.º do CDADC, que é lei especial face ao art. 10.º, n.º 2 do CDADC – “a alienação do negativo de uma obra fotográfica importa, salvo convenção em contrário, a transmissão dos direitos referidos nos artigos precedentes”.

Ora, esta é uma norma que não acompanhou a evolução da técnica. Actualmente, salvo ponderações de cariz idiossincrático, em que se desse primazia à estética da fotografia analógica, dificilmente a “produção fotográfica comercial” será realizada através de câmaras analógicas e consequente revelação do negativo – no limite, caso o fotógrafo quisesse alienar a “película original exposta”, antes da criação da imagem “positiva” final, alienaria o ficheiro de imagem capturado directamente pelo sensor da câmara fotográfica digital, o ficheiro .RAW, que pode ser entendido, *mutatis mutandis*, como o equivalente actual do negativo fotográfico. Todavia, atenta a excepcionalidade da norma do art. 166.º do CDADC, aplicando as regras gerais do Direito Civil (art. 11.º do CCiv), esta norma não é susceptível de aplicação analógica, pelo que, se o fotógrafo alienasse o “negativo digital”, não seria transmitido o direito de autor subjacente.

Embora o enunciado não o questione, recorde-se que a utilização da imagem da modelo está sujeita ao art. 79.º do CCiv e ao art. 7.º, n.º 2 al. e) do CP, exigindo autorização da própria; direito à imagem esse que é independente e cumulativamente aos direitos de autor sobre a fotografia.

Sintetizando a titularidade dos direitos de autor sobre a fotografia em apreço: (i) os direitos morais da sua contribuição pessoal (paternidade, integridade da obra, etc.), pertencem sempre ao fotógrafo, enquanto criador intelectual da fotografia; (ii) os direitos patrimoniais sobre o contributo individual (a fotografia) determinam-se pelo contrato de encomenda celebrado entre o fotógrafo e a agência (art. 14.º, n.º 1 CDADC *ex vi* 29.º, n.º 1 CP); na falta de convenção, e à luz da leitura correctiva do art. 29.º, n.º 2 do CP que sustentámos, fica reservado ao fotógrafo o direito exclusivo de utilização “em separado” da sua fotografia, sem prejuízo de a agência poder explorar o contributo enquanto integrado na obra colectiva (princípio do não prejuízo da exploração da obra colectiva, nos termos conjugados dos arts. 18.º, n.º 2 e 19.º, n.º 2 CDADC); (iii) se a obra publicitária

for obra colectiva, cabe à agência de publicidade a titularidade originária do direito de autor na obra no seu conjunto; (iv) A Miu Miu, enquanto anunciante, só é titular dos direitos patrimoniais na medida em que estes lhe tenham sido transmitidos pela agência no quadro do contrato de criação publicitária – podendo a transmissão consistir numa cessão plena dos direitos patrimoniais (translativa) ou em mera concessão/autorização/licença de utilização (não translativa), nos termos gerais do art. 40.º do CDADC.

Note-se que, sem a leitura correctiva do art. 29.º, n.º 2 do CP, valeria a presunção do art. 165.º, n.º 2 CDADC, “se a fotografia for efectuada (...) por encomenda, presume-se que o direito previsto neste artigo pertence (...) à pessoa que fez a encomenda.”, pelo que os direitos patrimoniais sobre a fotografia se presumiriam, caso não fosse afastada, na esfera da agência de publicidade. A leitura correctiva que sustentamos é precisamente a que limita esta presunção em favor da preservação do direito de utilização separada pelo fotógrafo.

2. Na publicidade aos cosméticos da **Lancôme** aparece a imagem de **Julia Roberts**, garantindo a empresa titular da marca que não houve filtros para retocarem a imagem da atriz após o uso dos cosméticos da marca (imagem à esquerda, abaixo). Ou seja, o anunciante e a agência de publicidade garantem que estamos perante uma fotografia da atriz sem utilizar cosméticos (à direita) e uma fotografia da atriz após o uso dos cosméticos (à esquerda) e que a fotografia da esquerda resulta apenas do efeito dos próprios cosméticos. Nada tem de manipulação digital.

Pronuncie-se sobre a veracidade destas afirmações e eventuais consequências quanto ao anúncio em causa.



R: A comunicação em apreço constitui “publicidade” na acepção do art. 3.º, n.º 1, al. a) do CP, por se destinar a “promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços”, *in casu*, cosméticos Lancôme. Em apreço está, no essencial, fazer um juízo sobre a veracidade²³ da mensagem publicitária e sobre a eventual subsunção ao conceito de publicidade enganosa (11.º do CP, que remete para

²³ Como desenvolveremos *infra*, este princípio visa acautelar o direito à informação dos consumidores e a garantia dos interesses económicos previstos no art. 60.º da CRP. No mesmo sentido, ANA AMORIM, Manual de Direito da Publicidade, s.1: Petrony Editora, p.71.

o RJPCD), bem como, em sede sectorial, o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, relativo aos produtos cosméticos²⁴.

Começando pelo princípio da veracidade, este é um dos princípios fundamentais²⁵ que regem a publicidade (art. 6.º CP), densificado pelo art. 10.º, n.º 1 do CP onde se lê que “a publicidade deve respeitar a verdade, não deformando os factos”. O n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que “as afirmações relativas (...) às propriedades (...) dos bens (...) publicitados devem ser exactas e passíveis de prova, a todo o momento, perante as instâncias competentes”.

A pretensa veracidade da mensagem publicitária²⁶ exige, no caso, que se demonstre cumulativamente: (i) que a fotografia da esquerda corresponde à Julia Roberts após o uso dos cosméticos da Lancôme; (ii) que essa fotografia não foi sujeita a qualquer manipulação (seja digital, seja analógica, seja com filtros, retoque, pós-produção, IA, etc.); e (iii) que o resultado visual nela patente é causalmente imputável apenas ao uso dos cosméticos anunciados.

Mesmo “a olho nu”, é manifesto que que a imagem da esquerda não apresenta um “rosto natural”, isto é, total ausência de rugas, a textura da pele (evocando uma boneca de cera) humanamente impossível tendo em conta a idade percebida da modelo (a actriz nasceu em 1967). Tal transformação excede, em muito, qualquer efeito plausível de produtos cosméticos, nomeadamente uma base ou um creme de rosto. É notório que a imagem foi retocada digitalmente²⁷, a comparar com a fotografia da actriz “na vida real” (à direita). As afirmações do anunciante são, pois, materialmente falsas,

²⁴ Art. 20.º do Regulamento citado, “(...) na publicidade dos produtos cosméticos, o texto, (...) as (...) imagens (...) não podem ser utilizados para atribuir a esses produtos características ou funções que não possuem”.

²⁵ O princípio da veracidade é tão fundamental que tem respaldo na CRP: este princípio implica *o respeito pela verdade*, sendo, por conseguinte, proibida a publicidade enganosa (a CRP denomina-a “dolosa”, art. 60.º, n.º 2 “sendo proibidas todas as formas de publicidade (...) dolosa”), isto é, a publicidade que induza ou possa induzir em erro os seus destinatários.

²⁶ Pois a empresa titular da marca garante, na mensagem publicitária, que a fotografia da esquerda corresponde à actriz após o uso dos cosméticos e que “a fotografia da esquerda resulta apenas do efeito dos próprios cosméticos” e que “não houve filtros para retocarem a imagem da actriz após o uso dos cosméticos da marca”. No fundo, a verificação da veracidade depende da quantidade de informação comunicada através da mensagem publicitária. Omitindo-se esta “garantia”, o juízo de veracidade incidiria apenas sobre se a actriz está a usar aqueles produtos da Lancôme e se está a usar só esses produtos.

²⁷ Nos últimos 15 anos, as técnicas (e as ferramentas) de manipulação digital de imagens evoluíram drasticamente, como também a nossa sensibilidade para distinguir o que é, do que não é, digitalmente alterado (hodiernamente, a tónica da questão coloca-se mais sobre o que é ou não é digitalmente *gerado...*), pelo que o “Photoshop” de 2010, e as fotografias nesse período alteradas, são, aos olhos dos dias de hoje, manifestamente manipuladas; todavia, “aos olhos” de 2010, a susceptibilidade da imagem *in casu* passar por “natural” era muito maior.

pois a experiência diz-nos que é impossível atingir estes resultados com a mera aplicação de uma base ou um creme.

O art. 11.º, n.º 1 do CP proíbe toda a publicidade que seja enganosa nos termos do RJPCD. O preceito faz uma remissão para os arts. 7.º (“acções enganosas”), art. 8.º (“acções consideradas enganosas em qualquer circunstância”²⁸) e art. 9.º (“omissões enganosas”)²⁹.

Nos termos do art. 7.º, n.º 1, b) RJPCD, é enganosa a prática comercial que contenha informações falsas (ou apresentação geral susceptível de induzir em erro) quanto às características principais do bem, designadamente “a sua execução”, “a sua composição”, “as utilizações” e, pertinentemente, “os resultados que podem ser esperados da sua utilização”. Ao apresentar como resultado real do uso dos cosméticos um efeito que, na verdade, foi obtido por manipulação digital, o anunciante distorce “de maneira substancial, o comportamento económico do consumidor” médio³⁰ (art. 5.º RJPCD), devendo, em concreto, ter-se em conta que a criação publicitária se dirige especialmente a um público feminino interessado em produtos anti-envelhecimento, frequentemente mais “vulnerável” a este tipo de promessas estéticas.

Nos termos conjugados dos art. 11.º, n.º 2 do CP e do art. 22.º do RJPCD, a entidade competente pode exigir ao anunciante a prova da exactidão material dos dados de facto contidos na publicidade: e, à luz do art. 11.º, n.º 3 do CP, “os dados referidos no número anterior presumem-se inexactos se as provas exigidas não forem apresentadas ou forem insuficientes”

A determinação das consequências começa, em rigor, no próprio tipo de prática comercial desleal. Nos termos do art. 4.º RJPCD, são proibidas as práticas comerciais desleais; o art. 5.º, n.º 1 define prática comercial desleal como “qualquer prática comercial desconforme à diligência profissional, que distorça ou seja susceptível de distorcer de maneira substancial o comportamento económico do consumidor seu destinatário ou que afecte este relativamente a certo bem ou serviço”; e o art. 6.º apresenta um elenco de práticas comerciais desleais “em especial”, e, nas al. b) e “as práticas comerciais enganosas (...) referidas nos artigos 7.º, 9.º e 11.º” e na al. c) as enganosas “consideradas como tal em qualquer circunstância” (lista negra do art. 8.º)

²⁸ Denominada “lista negra”

²⁹ Resultante da transposição da Directiva 2005/29/CE “directiva relativa às práticas comerciais desleais”

³⁰ Nos termos do art. 5.º, n.º 2 do RJPCD, o critério de aferição é o do consumidor médio – “normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”, tal como resulta da jurisprudência do TJUE, C-210/96 *Gut Springenheide*, § 31, “para determinar se a denominação, a marca ou indicação publicitária em causa eram ou não susceptíveis de induzir o comprador em erro...” *cit.*, acórdão citado.

A peça da Lancôme, que assim integra o tipo de prática comercial desleal por acção enganosa, em violação cumulativa dos arts. 6.º, 10.º, 11.º e 15.º, todos do CP e dos arts. 5.º, 7.º, n.º 1 al. b) e 9.º, todos do RJPCD. Daqui resultam, designadamente, as seguintes consequências:

No plano contra-ordenacional, a violação do art. 11.º do CP é punível, nos termos do art. 34.º, n.º 1, al. a) do CP, com coima de € 1.750 a € 3.750 (pessoa singular) ou de € 3.500 a € 45.000 (pessoa colectiva), sendo a negligência punível (art. 34.º, n.º 2 do CP). Cumulativamente (ou autonomamente) a conduta integra contraordenação económica grave, nos termos do art. 21.º, n.º 1 do RJPCD, punível pelo Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE, DL n.º 9/2021, de 29 de Janeiro). Tratando-se, como é o caso, de uma “campanha transfronteiriça” susceptível de constituir “infracção generalizada ao nível da União”³¹ na acepção do Regulamento (UE) 2017/2394, o tecto da coima ascende a 4% do volume de negócios anual do infractor ou, não estando disponível informação sobre o volume de negócios anual, até € 2.000.000 *ex vi* art. 21.º, n.ºs 2 e 3 do RJPCD.

Nos termos do art. 36.º do CP, são responsáveis pela contraordenação a Lancôme (anunciante), a agência publicitária (criação) e qualquer outra entidade interveniente na emissão da mensagem. A fiscalização compete, em matéria de publicidade, à Direcção-Geral do Consumidor (art. 19.º, n.º 3 RJPCD), que pode solicitar a colaboração da ASAE.

Podem ainda ser aplicadas, no quadro do art. 35.º CP, a apreensão dos objectos utilizados na prática da contraordenação (al. a)), a interdição temporária do exercício da actividade publicitária por período até dois anos (al. b)), a privação do direito ao subsídio outorgado por entidades públicas (al. c)) e o encerramento temporário das instalações ou cancelamento de licenças (al.d) – sanções que, sendo as previstas nas alíneas b), c) e d) nos termos do n.º 2, exigem dolo na prática da infracção. O n.º 4 admite, ainda, em casos graves ou socialmente relevantes, a publicidade da punição a expensas do infractor, dimensão sancionatória que, neste caso, pode ter peso reputacional não despreciando.

O anunciante, a agência e qualquer outra entidade interveniente respondem civil e solidariamente, nos termos do art. 30.º, n.º 1 CP, pelos prejuízos causados a terceiros (consumidores e, eventualmente, concorrentes). O anunciante apenas se exime se provar não ter tido prévio conhecimento da mensagem publicitária veiculada (art. 30.º/2 CP), ressalva manifestamente inutilizável quando a campanha é assumida e mundialmente difundida pela própria casa de cosméticos.

³¹ Art. 3.º, n.º 3 al. a) ou b) do Regulamento (UE) 2017/2394 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de protecção dos consumidores

A DGC pode, ao abrigo do art. 41.º CP e do art. 20.º RJPCD, e independentemente de culpa ou de prova de prejuízo real, ordenar a suspensão, cessação ou proibição da peça publicitária. O art. 41.º, n.º 4 CP permite conceder prazo para suprir os elementos ilícitos (p. ex., aposição de um *disclaimer* informando que a imagem foi tratada digitalmente, ou supressão da alegação 'sem retoque'), e o art. 41.º, n.º 7 CP autoriza a determinação de difusão de publicidade correctora a expensas do anunciante — medida com especial vocação reparadora face à confiança defraudada do consumidor.

Vale ainda o disposto no art. 14.º RJPCD: o consumidor que tenha celebrado contrato com fundamento em prática comercial desleal pode obter a redução do preço ou a resolução do contrato, com restituições nos termos das als. a) e b) do n.º 1, e ser ressarcido nos termos gerais (n.º 3), solução que, embora rara em produtos de baixo valor unitário, ganha protagonismo em compras de elevada quantia ou em modelos de subscrição.

Quanto à legitimidade activa, o art. 16.º RJPCD prevê que “qualquer pessoa, incluindo concorrentes” (p. ex., outras marcas de cosméticos) “que tenham interesse legítimo em opor-se às práticas comerciais desleais (...) pode intentar “a acção inibitória prevista na Lei n.º 24/46, de 31 de Julho, com vista a prevenir, corrigir ou fazer cessar tais práticas”. Os concorrentes podem ainda suscitar a intervenção da DGC nos termos do art. 42.º CP

No plano autorregulatório, a peça pode ser objecto de queixa junto do Júri de Ética da ARP, ao abrigo do Código de Conduta, que densifica os princípios da Honestidade, Veracidade e Responsabilidade Social, com determinação de cessação imediata e publicitação da decisão. A precedência do caso real Lancôme/Teint Miracle (decidido pela ASA britânica em 2011, que proibiu a campanha exactamente por a L'Oréal não ter conseguido demonstrar a inexistência de retoque digital) é, aqui, particularmente eloquente. A eficácia reputacional desta sanção é, no plano sectorial, frequentemente superior à da própria coima.

3. Uma conhecida *influencer* de moda (**Chiara Ferragni**) foi acusada de ter apoiado a publicidade de uma marca de “Pandoro”, bolo de Natal típico em Itália, com uma alegada doação a instituições de caridade por unidade vendida que não ocorria nos termos anunciados. Esta ato marcou a descida aos infernos desta conhecida *influencer* de moda.

Foi processada por fraude agravada por uma associação de consumidores italiana (a Coddacons), mas acabou por ser absolvida, embora se tivesse provado ter havido publicidade enganosa. O que explica esta absolvição? Justifique, supondo que seria de aplicar ao caso mesmo regime do direito da publicidade português.

Embora não tivesse sido condenada, a *Influencer* perdeu muitos seguidores e patrocínios importantes. Na sua resposta, tenha em conta estes factos.



R: O conceito de publicidade do art. 3.º, n. 1º do CP assenta em três elementos: objectivo (qualquer forma de comunicação), subjectivo (entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal) e teleológico (objectivo directo ou indirecto de: al. a) promover bens ou serviços, al. b) promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições)

A estes três elementos, a auto-regulação europeia³² acrescenta dois critérios operativos para o *influencer marketing*: (i) existência de pagamento (em dinheiro ou em espécie, tais como, produtos oferecidos, viagens, descontos, doações em nome da *influencer*) e (ii) o controlo editorial da “marca”³³ sobre o conteúdo publicado pela *influencer*³⁴.

No caso da Chiara Ferragni, todos estes elementos estão presentes: existiu uma comunicação, por parte de uma pessoa singular (“entidade privada”), com objectivo de promover bolos da marca “Pandoro” (bens), *in casu*, um post patrocinado (*endorsement deal*³⁵) com remuneração paga pela marca de “Pandoro” e com controlo editorial da marca sobre a campanha (a associação solidária a instituições de caridade) – concluindo, portanto, que há publicidade, máxime, *influencer marketing* e o post patrocinado é a mensagem publicitária.

O CP define anunciante como a “pessoa singular ou colectiva no interesse de quem se realiza a publicidade” (art. 5.º, n. º1 a) do CP), sendo profissional ou agência de publicidade “a pessoa singular que exerce actividade publicitária ou a pessoa colectiva que tenha por objecto exclusivo o exercício da actividade publicitária” (art. 5.º, n. º1, al. b) do CP)³⁶. Assim sendo, quanto ao conceito de *influencer*³⁷ e no que consiste, sumariamente, a sua actividade, o *influencer* é considerando um profissional de publicidade quando: (i) tem um controlo efectivo sobre o seguimento da campanha, possuindo um conhecimento preciso sobre o seu público e o que funciona com este a nível publicitário, ou (ii) está sujeito a um *briefing* sobre o conteúdo da mensagem e/ou

³²EASA Best Practice Recommendation on Influencer Marketing, 2018, vinculativo para a ARP, membro da EASA). A European Advertising Standards Alliance – EASA foi constituída em 1992, é uma associação de 41 organizações que visam assegurar a responsabilidade publicitária através da auto-regulação, que inclui a ARP, anteriormente designada por ICAP. O CAP CODE, britânico, prevê a existência dos mesmos dois elementos.

³³ Entenda-se, o *marketer* – abrangendo, portanto, o anunciante (5.º, n. º1, a) CP)

³⁴ Ou seja, se é disponibilizado um *briefing*, se é necessária aprovação para o conteúdo ser publicado, se este está sujeito a revisão, se a marca envia um produto ao *influencer*, em sequência de contacto prévio, com o objectivo que este faça uma referência ao que foi enviado, considera-se este elemento preenchido.

³⁵ Nos posts patrocinados, o *influencer* recebe uma compensação por publicidade ao serviço, sendo o seu conteúdo indicado pela marca – distinguindo-se, portanto, dos *anúncios patrocinados* (i.e, posts a fazer publicidade a um produto ou serviço, mediante pagamento por parte do anunciante à plataforma)

³⁶ ANA AMORIM refere que “o anunciante toma a iniciativa da publicidade e assume os respectivos encargos financeiros”, já o profissional ou agência de publicidade cabe “a negociação e contratação de espaço e de tempo com os meios, bem como a avaliação dos resultados, sendo uma entidade especializada no sector da comunicação comercial, com intervenção directa na concepção, criação, produção e planificação da campanhas, em estreita colaboração com os anunciantes”, *cit.*, ANA AMORIM, Manual... *op. cit.*, pp. 44-46

³⁷ Indivíduos que exercem, em plataformas digitais, uma actividade de difusão de um novo produto ou serviço, com vista a sua adopção, aumentando o *engagement* online do produto ou serviço publicitado, moldando comportamentos e decisões do público, tendo em vista um objectivo económico.

da campanha³⁸, que fica sujeita a aprovação antes da sua publicação. No quadro do RJPCD, o *influencer* será também um “profissional”, na acepção deste regime, cfr. art. 3.º, n.º 1, al. b) do RJPCD, pois “actua no âmbito da sua actividade comercial”.

Aplica-se, portanto, à mensagem publicitária da *influencer*, os mesmos princípios (art. 6.º CP) que se aplicam às demais mensagens publicitárias, pois, neste plano, ainda embrionário, da análise, o elemento subjectivo não acarreta, tendo em conta os circunstancialismos do caso, grandes especificidades; dos princípios fundamentais do CP, destacamos, *in casu*, o princípio da licitude (art. 7.º CP), o princípio da veracidade (art. 10.º CP) e o respeito pelos direitos do consumidor (art. 12.º CP).

E: Foi processada por fraude agravada por uma associação de consumidores italiana (a Coddacons), mas acabou por ser absolvida, embora **se tivesse provado ter havido publicidade enganosa**.

O que explica esta absolvição? Justifique, supondo que seria de aplicar ao caso mesmo regime do direito da publicidade português

R: Quanto ao mesmo facto jurídico, podem ser retiradas diferentes consequências jurídicas, consoante a hipótese legal da norma jurídica que este preenche.

Sabemos que as normas, de uma forma geral, contêm uma descrição de uma ou mais categorias de acontecimentos; normalmente, trata-se da descrição de uma situação típica de conflito de interesses (um *tipo* de conflitos). Por outro lado, essa situação típica de conflito remete para uma *questão jurídica* específica.

Conforme nos foi ensinado, um facto jurídico, é um facto juridicamente relevante³⁹, um evento que produz efeitos jurídicos; ora, aquilo que confere relevância jurídica a certo facto, que o converte num *facto jurídico*, é justamente a referência feita a esse facto na hipótese legal de uma *norma jurídica* (não é o *facto* em si que é integrado na previsão da norma, mas sim uma *descrição* desse facto, ou, melhor, a descrição de uma *categoria* de factos, feita de forma abstracta, na qual se insere aquele facto concreto através de um processo de comparação). Uma vez verificado um facto integrável nessa categoria ou tipo, a norma associa a essa verificação uma certa *consequência jurídica*; essa consequência traduz-se, *grosso modo*, na constituição, modificação, ou extinção de uma relação jurídica, que é o mesmo que dizer, na constituição, modificação e extinção de direitos e deveres.

³⁸ P.ex., se a marca pretende um link na biografia de Instagram do *influencer*, na descrição do post, no *swipe up* do *story*, indicações sobre o tipo de foto, os hashtags da campanha, etc.

³⁹ “Diz-se facto jurídico o evento juridicamente relevante – i.e., susceptível de produzir efeitos de direito.” *cit.*, J. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 12.ª reimpressão, Almedina, Novembro, 2000, p. 82.

Assim, quando certo caso é apresentado ao julgador, aquilo que este faz é tentar perceber qual a *questão jurídica* envolvida. O julgador tenta *identificar* o problema jurídico envolvido. Esta operação mental levada a cabo pelo julgador, ou seja, identificar numa determinada situação de facto a manifestação de certa questão jurídica (um *caso* na hipótese legal de certa norma), também se chama *qualificação*: o julgador *qualifica* o problema a resolver naquela situação de facto⁴⁰.

Feita esta “súmula” e voltando ao caso em apreço, como dissemos, quanto ao mesmo facto, podem ser retiradas diferentes consequências, consoante a norma que este preenche. Ora, a situação de facto em causa preenche a hipótese legal de “publicidade enganosa” da norma do art. 11.º, n. 1º CP.

Vejamos, sem saltar passos: a publicidade enganosa é “proibida”, nos termos do artigo referido, e será “enganosa”, toda a publicidade (art.º 3, n. 1º CP) que seja “enganosa nos termos do Decreto-Lei n.º 57/2008, e 26 de Março, relativo às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores. [o RJPCD]”

Temos, portanto, uma remissão extralegislativa para o RJPCD para *qualificar* o caso “publicidade” como “enganosa”. Para o efeito, temos diversas normas no RJPCD.

No art. 7.º, n. 1º, do diploma referido, será “enganosa” a “prática comercial que contenha informações falsas ou que, mesmo sendo factualmente correctas, por qualquer razão, nomeadamente a sua apresentação geral, induza ou *seja susceptível de induzir em erro* o consumidor em relação *a um ou mais dos elementos a seguir enumerados* e que, em ambos os casos, conduz ou é *susceptível de conduzir* o consumidor a *tomar uma decisão de transacção que este não teria tomado de outro modo*”. A al. a) do referido artigo fala em “existência ou a natureza do bem ou serviço” e a al. b) “as características principais do bem ou serviço, tais como (...) a adequação ao fim a que se destina” e, mais pertinentemente, a al. c) “o conteúdo e a *extensão dos compromissos assumidos pelo profissional, a motivação da prática comercial* (...) a utilização de qualquer *afirmação* ou símbolos indicativos de que o *profissional* [a *influencer*], o bem ou o serviço beneficiam, directa ou indirectamente, de *patrocínio ou de apoio*”

Como vimos, a *influencer* é uma “profissional”, e o exercício da actividade publicitária é a sua “prática comercial”, nas acepções deste diploma. *In casu*, a *influencer* apoia a publicidade da marca “Pandoro”, na promoção do bem “bolo de Natal”, com a *motivação da prática comercial* ser a doação a instituições de caridade por unidade vendida (*o conteúdo e a extensão dos compromissos assumidos*), que não ocorreu nos termos anunciados. Esta informação é idónea a induzir o consumidor (tomando como

⁴⁰ A. MANUEL HESPANHA, *O Caleidoscópio do Direito. O Direito e a Justiça nos Dias e no Mundo de hoje*, 2.ª ed., Almedina, 2009, pp. 631 e ss.

critério para aferir o carácter (des)leal o “consumidor médio” ou o “membro médio de um grupo”, art. 5.º, n. 2) a tomar uma decisão de transacção que este de outro modo não tomaria.

Pelas razões elencadas, cremos não estar longe da verdade ao afirmar que a comunicação comercial contém informação falsa e a sua apresentação geral é idónea de induzir em erro o consumidor médio quanto aos motivos da prática comercial e a extensão dos compromissos assumidos – pelo que, afirmamos que estamos perante publicidade enganosa⁴¹.

Qualificada a publicidade como enganosa, esta a situação fáctica preenche a totalidade da *factispecies* do art. 11.º do CP (ser publicidade e ser enganosa), olhemos para a estatuição da mesma: “é proibida”. A norma, interpretada sozinha, é, portanto, uma norma jurídica imperfeita⁴², pois estabelece um dever/proibição, mas não prevê nenhuma sanção para a sua violação. Todavia, o Direito é um sistema: apesar de na própria norma não se enunciar nenhuma sanção, proibindo apenas, em termos gerais, a publicidade enganosa, tal não significa que não existam outras normas que constituam/modifiquem/extingam direitos ou obrigações aquando da sua violação.

E aqui, voltamos ao já dito: quanto ao mesmo facto, podem ser retiradas diferentes consequências, consoante a hipótese legal de determinada norma.

Para efeitos do RJPCD, o art. 21.º, n.º 1 prescreve que “a violação do disposto nos artigos 4.º a 12.º *constitui contraordenação económica grave*, punível nos termos do Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE)”. Temos aqui uma “perfeição” da norma anteriormente escalpelizada.

Para efeitos do CP, o art. 34.º, n. 1 estabelece que “a infracção ao disposto no presente diploma *constitui contraordenação* punível com as seguintes coimas”. Encontramos aqui, outra “perfeição” do art. 11.º do CP.

Para efeitos do Código Penal (“CPenal”)⁴³, o art. 217.⁴⁴ preceitua que “Quem, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento ilegítimo, por meio de erro

⁴¹ Na “lista negra” de “acções consideradas enganosas, em qualquer circunstância” (art. 8.º RJPCD) releva a alínea z) “alegar falsamente ou da impressão de que o profissional não está a agir para fins relacionados com a sua actividade comercial” uma vez que, alegadamente, o exercício da actividade publicitária tinha fins meramente altruísticas, que não visavam o lucro.

⁴² Em bom rigor, uma norma menos que perfeita (*lex minus quam perfecta*) pois estabelece uma “sanção” (uma proibição), mas não os efeitos jurídicos da sua violação.

⁴³ Uma vez que o enunciado menciona “fraude qualificada”, que entenderemos como burla qualificada, uma vez que estamos a tratar a questão à luz da lei portuguesa e é esse o nosso *nomen iuris*.

⁴⁴ Mais propriamente, e atenta a notoriedade da *influencer* e a dimensão da campanha, extensível a milhares de consumidores, a Codacons pugnou por *truffa aggravata*, cujo equivalente português é a burla qualifica do art. 218.º CPenal. O art. 218.º, n. 2 al.c) prevê expressamente o agravamento quando o agente

ou engano sobre factos que astuciosamente provocou, determinar outrem à pratica de actos que lhe causem, ou causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial *é punido com pena de prisão* até 3 anos ou com *pena de multa*”. Outra “perfeição” do art. 11.º do CP? Em bom rigor, não. Porquê? Pois o facto jurídico referido na hipótese legal da norma do CPenal não é o mesmo facto jurídico (publicidade enganosa) *qualificado* na norma do CP – ainda possa ser o mesmo facto juridicamente relevante, a mesma situação fáctica!

Por outras palavras, a burla pode ser feita através de publicidade enganosa, mas a publicidade enganosa não pressupõe burla.

O enunciado linguístico é diferente, logo, descreve uma outra categoria de acontecimentos (que podem se concretizar na mesma situação fáctica, uma vez que a norma é geral e abstracta); e, como vimos, caberá ao julgador, novamente, perceber qual é a questão jurídica envolvida, subsumir os factos ao direito, para saber se o facto jurídico pode ser *qualificado* (também) na norma do CPenal.

São elementos constitutivos (objectivos e subjectivos) do crime de burla⁴⁵: (i) o emprego de astúcia pelo agente; (ii) o erro ou engano da vítima devido ao emprego da astúcia; (iii) a prática de actos pela vítima em consequência do erro ou engano em que foi induzida; (iv) o prejuízo patrimonial da vítima ou de terceiro resultante da prática dos referidos actos; e (v) a intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento ilegítimo.

Para o que importa para responder à pergunta colocada pelo enunciado, “Foi processada por fraude agravada por uma associação de consumidores italiana (a Coddacons), mas **acabou por ser absolvida, embora se tivesse provado ter havido publicidade enganosa.**”, a absolvição, mesmo provada a publicidade enganosa, não é, portanto, dogmaticamente, paradoxal. Explica-se pela diferença entre os “ilícitos” resultantes das normas referidas (dois de mera ordenação social, outro criminal, respectivamente), as consequências jurídicas da ilicitude (em sedes diferentes) e, principalmente, pela descrição de diferentes categorias de eventos nas hipóteses legais das normas referidas.

Entenda-se, pelas razões expostas, e como já foi afirmado, a actividade publicitária *in casu* é publicidade enganosa. Sendo enganosa, é proibida. Sendo proibida, e tendo acontecido, é, simultaneamente, uma infracção “ao disposto no presente diploma⁴⁶” (CP), logo “constitui contraordenação punível com as seguintes coimas” e

“se tiver aproveitado de especial situação de vulnerabilidade da vítima;” a al. b) – o agente fazer da burla modo de vida – também já foi mobilizada em casos de *influencer marketing*.

⁴⁵ Interpretação do 217.º do CPenal sufragada pelo Tribunal da Relação de Évora, 20/05/2014, Processo n.º 1915/13.1TASTB.E1, Relator: Alberto João Borges

⁴⁶ Art. 34.º, n.º 1 CP.

uma “violação do disposto nos artigos 4.º a 12.^º⁴⁷” do RJPCD, logo “constitui contraordenação económica grave”. Pela força do próprio Direito (*ipso iure*), existindo uma “infracção” e uma “violação” (a publicidade enganosa preenche as duas), há a constituição de duas contraordenações, assentes na mesma situação fáctica.

Ora, voltando aos elementos típicos do crime de burla, a “publicidade enganosa” não é um elemento típico – pelo que, é perfeitamente possível que, em sede criminal, se tenha provado que houve publicidade enganosa, mas tal não seja suficiente, face aos circunstancialismos, para preencher os elementos típicos do ilícito criminal burla.

É verdade que, lendo a hipótese legal do art. 217.º do CP, e tendo em conta *todo* o caso narrado no enunciado, parecem estar preenchidos os elementos típicos de burla, pois há emprego de astúcia pela *influencer*, ocorreu erro ou engano por parte de quem comprou os bolos de Natal (como vimos para efeitos de determinação se existia, ou não, publicidade enganosa), prejuízo patrimonial da vítima e intenção de obter para si ou para terceiros, enriquecimento ilegítimo.

Todavia, em sede criminal, é necessário que se *prove* o dolo específico de obter, para si ou para terceiro, o enriquecimento ilegítimo (a *influencer* recebeu uma remuneração pela campanha, mas a remuneração é em si lícita. Para haver dolo específico de burla teria de provar-se que a *influencer* representou e quis a indução em erro do consumidor com vista a uma vantagem patrimonial ilegítima, sua ou da marca de “Pandoro”. Em sede criminal, vale o princípio *in dubio pro reo* (art. 32.º, n.º2 CRP) e demonstrar a representação e vontade dolosas da *influencer* no quadro de uma campanha enorme pode ser, na prática, difícil [também a questão da prova do nexo de causalidade e do prejuízo patrimonial individualizado – repare-se, cada consumidor pagou, p.ex., € 9 e recebeu efectivamente o bolo de Natal, tal como anunciado; o “prejuízo” seria, quando muito, a frustração do destino solidário da transacção, dificilmente quantificável e de natureza não patrimonial, ficando de fora do bem jurídico tutelado pela burla, que é especificamente o património. Acresce ainda que dificilmente se sustentará que o “consumidor médio” (art. 5.º, n.º 2 do RJPCD) decidiu a compra do bolo de Natal exclusivamente em função do cariz solidário da campanha publicitária, dificultando a tal prova do nexo causal.)

Mais ainda, o art. 217.º do CPenal exige ainda que o erro ou engano “tenham sido provocados astuciosamente pelo agente da infracção; isto é, usando um meio engenhoso para enganar ou induzir em erro. Trata-se de uma exigência que acresce um dolo que já de *per si* é específico, pois que se exige a intenção enriquecimento

⁴⁷ Art. 21.º, n.º1 RJPCD

ilegítimo”⁴⁸ – algo qualitativamente superior a um exagero publicitário ou a uma mensagem ambígua (outros “casos” de publicidade enganosa).

O regime contra-ordenacional tutela exactamente esta “zona cinzenta” de informação inexacta, ambígua ou capciosa que não é “astuciosa” em sentido típico-criminal⁴⁹.

Todavia, não nos cabe aqui fazer uma crítica sobre a decisão do tribunal italiano a questão que se coloca, verdadeiramente é porque é que a “[a *influencer*] **acabou por ser absolvida** [do processo-crime], **embora se tivesse provado ter havido publicidade enganosa**” e “**o que explica esta absolvição?**”

Pelo que sintetizamos: a absolvição não desmente que tenha existido publicidade enganosa; confirma, apenas, que a existência de publicidade enganosa não foi, naquele caso, suficiente para se qualificar como burla.

E: Embora não tivesse sido condenada, a *Influencer* perdeu muitos seguidores e patrocínios importantes. Na sua resposta, tenha em conta estes factos.

R: A propagação dos blogues pessoas e das redes sociais veio alterar o paradigma das relações de mercado, passando a haver uma ampla disponibilidade de informação relativa aos produtos e serviços bem no recurso aos *influencers* para promoverem uma imagem favorável dos produtos. A evolução digital é uma realidade bem presente no quotidiano das empresas, proporcionado a criação de novos modelos de negócio e transformando a forma como uma empresa se relaciona com os seus clientes, impulsionado o surgimento de novas formas de interacção e de comunicação com o seu público-alvo. Uma das grandes revoluções da Web 2.0 foi a democratização da interacção dos consumidores com a Internet, partilhando informações sobre os produtos e serviços. Tal partilha de informações fez com que houvesse um afastamento do predomínio dos produtores e distribuidores, transferindo para os consumidores um papel fundamental nas relações de mercado⁵⁰.

⁴⁸ MAIA GONÇALVES, Código Penal Português Anotado e Comentado, 11.ª Edição, 1197, Almedina Coimbra, p. 650, citado pelo Supremo Tribunal de Justiça, 09/05/2019, Processo n.º 10/16.PGPD.LS1, Relator: Raul Borges

⁴⁹ Por último, o Direito penal é a *última ratio* do ordenamento sancionatório (art. 18.º, n.º 2 CRP). Quando a tutela contraordenacional é, em concreto, suficiente para reprimir e prevenir o ilícito, não se justifica – nem se permite – fazer descer a “espada” do Direito Penal sobre o agente. A absolvição

⁵⁰ Cfr. ANA AMORIM, “Estratégias Comerciais: marketing e publicidade” In J.F. CASTRO (coord.), Fashion Law, Direito da Moda, Navarra, Arazandi, 2019, pp. 861-894, disponível em <http://hdl.handle.net/11328/3181>

A revolução do poder do mercado aliado à saturação publicitária, provocou uma alteração nas estratégias utilizadas pelos anunciantes para captar a atenção dos consumidores.

No âmbito da autorregulação, as entidades responsáveis não têm poderes sancionatórios consideráveis e, por isso, as suas decisões passam muito pela interrupção, alteração ou remoção das publicações que infrinjam as normas dos seus códigos⁵¹. Porém, mesmo na ausência de poder coercitivo, o escândalo pode ter cobertura pelos media, existindo hipótese de a imagem da marca ou do *influencer* ficar afectada, bem como as colaborações com outros potenciais intervenientes em outras campanhas/actividades publicitárias serem comprometidas. Foi exactamente isso que sucedeu: a absolvição penal coexistiu com a perda massiva de seguidores, com a rescisão de contratos com marcas e com a quebra do valor de mercado da *influencer* enquanto activo publicitário (a reputação, no contexto do *influencer marketing*, integra o direito ao bom nome (art. 26.º CRP, art. 70.º CCiv) e constitui o principal activo económico do agente: a sua autoridade junto dos seus seguidores).

Quando essa reputação é colocada em causa opera “sanção social” ajurídica pela comunidade⁵²: queda do *engagement*, fuga de seguidores, rescisão dos contratos de patrocínio (com cláusulas resolutivas frequentemente accionáveis por *moral clauses*, no fundo, “cláusulas de salvaguarda reputacional”). Estas consequências surgem ainda que a justiça absolva, porque o público e as marcas avaliam a conduta segundo critérios éticos e de confiança, não jurídico-criminais. Como dissemos *supra*, “as colaborações com outros potenciais intervenientes em outras campanhas/actividades publicitárias [podem ser] comprometidas”.

Em Portugal, esta sanção informal pode ser secundada por responsabilidade contratual (p.ex., incumprimento de cláusulas de comportamento e veracidade nos contratos de embaixadora ou de difusão publicitária, nos termos dos arts. 798.º e segs. CCiv,) ou até mesmo, resolução dos contratos por alteração anormal de circunstâncias (art. 437.º, n.º 1 CCiv).

Acresce uma via de responsabilização civil, esta aquiliana. O art. 485.º, n.º 1 CCiv exclui, em regra, a responsabilidade por simples conselhos, recomendações ou informações; mas o n.º 2 ressalva-a quando exista assunção de responsabilidade, quando havia o dever jurídico de dar a informação e o agente actuou com negligência ou intenção de prejudicar, ou quando o procedimento constitua facto punível. Como nota

⁵¹ Em Portugal, veja-se o Proc. 1J/2022 da ARP (IAP vs. Prozis, de 27.04.2022), em que se determinou a retirada de posts de influencers não identificados com '#PUB' no início da mensagem: decisão demonstrativa do alcance, ainda que limitado, da autorregulação portuguesa neste domínio.

⁵² Referimo-nos à *cancel culture*.

MENEZES LEITÃO⁵³, há que distinguir “indicações circunstanciais” de “verdadeiros conselhos, recomendações ou informações”. Estes últimos, os do *influencer* perante uma comunidade que confia na sua opinião e por isso decide consumir, determinam a actuação dos seguidores com base em confiança, sendo, a nosso ver, susceptíveis de gerar responsabilidade civil quando provoquem danos por informações falsas. Não é, portanto, indiferente que o *influencer* “publique opinião” ou “publique opinião remunerada”.

Em jeito de conclusão, a dissociação entre a absolvição e a queda reputacional revela, no nosso entender, algumas conclusões úteis para o regime do direito da publicidade: (i) a perda de patrocínios e a queda de seguidores demonstram que o sistema autorregulatório e a sanção ajurídica difusa da comunidade podem ter um efeito dissuasor superior ao das próprias coimas, sobretudo no *influencer marketing*; (ii) o cumprimento estrito dos princípios da licitude, identificabilidade, veracidade e respeito pelos direitos do consumidor (arts. 6.º a 13.º CP) é hoje condição indispensável de continuidade da actividade de *influencer*, porque qualquer falha é amplificada pelo próprio meio digital – sendo este, até, o efeito mais imediato e mais penalizador.

⁵³ MENEZES LEITÃO, “As Práticas Comerciais Desleais nas Relações de Consumo” In Revista da Ordem dos Advogados, ano 71, vol. II - Abr/Jun, 2011, pp. 423-445.

4. Construa uma hipótese concreta de concorrência comparativa e distinga-a de uma situação concreta de concorrência desleal.

Hipótese de publicidade comparativa: O Pingo Doce difunde nos seus folhetos e em televisão uma campanha em que apresenta uma tabela comparativa com os preços de 10 produtos da “marca branca”⁵⁴ “Pingo Doce” e os respectivos equivalentes funcionais da marca branca “Continente”, indicando, para cada item, a diferença em euros e a poupança total no cabaz. A peça identifica claramente ambos os concorrentes, apresenta uma tabela (data e local de recolha dos preços dos produtos e sua quantidade) e termina com o *slogan* “Pingo Doce. Mais barato em produtos essenciais.”⁵⁵.

O art. 16.º, n.º 1 do CP determina que “é comparativa a publicidade que identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos por um concorrente”. *In casu*, a mensagem integra o conceito de publicidade (art. 3.º, n.º 1 a) do CP), e é comparativa pois identifica (explicitamente) os bens ou serviços oferecidos por um concorrente (“Continente”) (16.º, n.º 1 CP, 2.º parte)

O art. 16.º, n.º 2 do CP determina que a “publicidade comparativa (...) só é consentida, no que respeita à comparação, desde que respeite as seguintes condições:”, elencando nas suas alíneas as tais “condições”. Vejamos, portanto, se a hipótese desenhada configura publicidade comparativa (explícita, de bens ou serviços de um concorrente) é “consentida” (ou seja, se é lícita)

- alínea a) – não é enganosa, nos termos do art. 11.º CP e do art. 7.º do RJPCD uma vez que os preços são factualmente correctos⁵⁶ (sobre o anunciante recai o ónus da prova: art. 16.º, n.º 5 CP);
- alínea b) – compara bens que respondem às mesmas necessidades (cabaz de produtos essenciais idênticos);
- alínea c) – a comparação é objectiva e incide sobre uma característica essencial, pertinente, comprovável e representativa, que é o preço, aliás, característica essa que o próprio legislador admite na norma em questão “(...) entre as quais se pode incluir o preço”.

⁵⁴ Ou “produtos do distribuidor”.

⁵⁵ Repara-se, que apenas diz que é “mais barato”; caso fosse, p.ex., “Pingo Doce. A melhor escolha em produtos essenciais”, não estaria a ser feita uma comparação objectiva, mas antes qualitativa.

⁵⁶ É verdade que a mensagem “conduz, ou é susceptível de conduzir o consumidor a tomar uma decisão de transacção que este não teria tomado de outro modo”, mas não é “enganosa”, tão-pouco “induz em erro o consumidor”, para efeitos do art. 7.º, n.º 1 RJPCD – a susceptibilidade de o consumidor tomar outra decisão resulta do teor informativo da mensagem, que se deve ter como desejável, por se tratar de uma comunicação aos consumidores de forma transparente e objectiva sobre a realidade do mercado, incentivando ao consumo responsável e informado.

- alínea d) – não gera confusão no mercado (são distintos e expressamente identificados os sinais distintivos e os bens/serviços do anunciante e do concorrente);
- alínea e) – não desacredita nem deprecia o concorrente, limitando-se à indicação do diferencial de preço;
- alínea f) – para a hipótese, não estão em causa produtos com denominação de origem; se estivessem, teriam que ser produtos com a mesma denominação, não bastando “bens ou serviços que respondam às mesmas necessidades ou que tenham os mesmos objectivos”, como prescreve a alínea b).
- alínea g) – não retira partido indevido do renome do concorrente, sendo a referência a este meramente instrumental para que se possa verdadeiramente comparar;
- alínea h) – não apresenta o seu produto como imitação ou reprodução.

Ressalve-se que, em caso de oferta especial (vulgo, “promoções”) associada à comparação, deveria observar-se ainda o disposto nos n.ºs 3 e 4 do art. 16.º CP.

Data: 2 de Maio de 2026

Fizemos uma seleção de produtos da marca do distribuidor

Comparámos:

os mesmos produtos

a mesma capacidade

comprados no mesmo dia, na mesma localidade

excluimos produtos em promoção

Pingo Doce. Mais barato em produtos essenciais.

Produto	Quantidade	 		Preço €/kg ou L (PD vs Cont.)
		Pingo Doce	CONTINENTE	
Leite meio-gordo UHT	1 L	0,89€	0,92€	0,89 vs 0,92 €/L
Iogurte grego natural	4x125g (500g)	1,39€	1,49€	2,78 vs 2,98 €/kg
Arroz carolino	1 kg	1,09€	1,15€	1,09 vs 1,15 €/kg
Massa esparguete	500 g	0,69€	0,75€	1,38 vs 1,50 €/kg
Azeite virgem extra	750 ml	5,49€	5,79€	7,32 vs 7,72 €/L
Atum em lata	120 g (escorrido ~84g)	0,79€	0,85€	~9,40 vs 10,10 €/kg
Bolachas tipo Maria	200 g	0,59€	0,65€	2,95 vs 3,25 €/kg
Detergente da roupa	30 doses (~2 L)	6,99€	7,49€	~3,50 vs 3,75 €/L

* Comparação realizada no Porto, no dia 2 de Maio, entre produtos da marca do distribuidor, com igual quantidade e características, excluindo ofertas especiais, com base no preço por unidade e medida.

Nestes termos, esta hipótese será considerada uma publicidade comparativa lícita.

Hipótese de concorrência desleal:

A “Mafarricos, Lda.”, sociedade de cosméticos que entrou no mercado em 2026, decide concorrer com a “BeautyLab, S.A”, líder histórica do segmento de cremes de rosto há mais de 100 anos, pelo efeito lifting (conhecido até por “efeito Beauty”) do seu “BeautyLab Original”. Para o efeito:

- i. Lança um creme designado “Beauty Plus”, em embalagem cuja disposição gráfica reproduz com mínimas variações o packaging do creme “BeautyLab Original”
- ii. Publica posts patrocinados em redes sociais declarando que “A BeautyLab Original é antiga, provoca alergias e já foi retirada do mercado em França. Adaptamos a tecnologia e criamos o Beauty Plus” (informação falsa e nunca demonstrada)
- iii. Usa nas mensagens publicitárias a expressão “a verdadeira sucessora da BeautyLab.” “O mesmo efeito “*beauty*” do creme que sempre usou. Fórmula melhorada.”

Como descreveu KOHLER⁵⁷ num enunciado clássico, recuperado por NUNO SOUSA E SILVA⁵⁸, “a deslealdade é um Proteus que se refugia em mil formas, evita as figuras previstas na lei e através de um incontável número de disfarces toma os frutos do esforço honesto no comércio leal”. Esta plasticidade do instituto explica a opção do legislador português pela técnica da cláusula geral prevista no ordenamento jurídico português no art. 311.º do CPI. É notório que estamos, na hipótese desenhada, perante actos contrários às normas e usos honestos do comércio, subsumíveis ao princípio geral. Concretizando, e correndo as alíneas pertinentes do elenco exemplificativo do 311.º, n.º 1 do CPI:

Quanto ao acto i), reprodução do *packaging*: preenche-se a alínea a): “actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue”.

Quanto ao acto ii), falsidade sobre alergias e retirada do mercado em França, preenche-se a alínea b): “falsas afirmações feitas no exercício de uma actividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes”.

Quanto ao acto iii), o slogan “a verdadeira sucessora da BeautyLab” e apropriação do termo “efeito beauty”, preenche-se a alínea c): “invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome,

⁵⁷ *Recht des Markenschutzes*, 1884

⁵⁸ NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os Atos de Aproveitamento*, Almedina, 2020, *cit.*, p. 223.

estabelecimento ou marca alheios”. Trata-se de apropriação parasitária de mais de um século de reputação acumulada pela BeautyLab, com vista a transferir esse “capital reputacional” para a Mafarricos sem “o esforço honesto do concorrente leal”.

Na hipótese desenhada, procuramos demonstrar as três grandes categorias dogmáticas de concorrência desleal: actos de confusão (al. a)), actos de descrédito (al. b)) e actos parasitários (al. c)). Como sublinha NUNO SOUSA E SILVA, “enganar os consumidores é uniformemente considerado negativo e desleal”. *In casu*, temos engano quanto à origem do produto (al. a)), engano quanto à reputação do concorrente (al. b)) e engano quanto à filiação comercial (al. c)).

Distinção:

Apresentadas as duas hipóteses, importa traçar agora a fronteira que as separa, à luz dos critérios que, em concurso, a doutrina e o direito positivo mobilizam. Os dois institutos: publicidade comparativa (art. 16.º CP) e concorrência desleal (art. 311.º CPI). Distinguem-se, em quatro planos essenciais.

Primeiro, no plano da licitude. A publicidade comparativa é, em si mesma, lícita (e, mais do que isso, *desejável*, na medida em que estimula a concorrência informativa e densifica o direito à informação do consumidor [art. 60.º, nn.º CRP]). O legislador, no art. 16.º/2 CP, limita-se a sujeitá-la ao cumprimento cumulativo de oito requisitos taxativos. Já a concorrência desleal é, por definição e em qualquer das suas modalidades, ilícita: a sua *factispecies*, ancorada na cláusula geral do art. 311.º, n.º 1 CPI, traduz-se na contrariedade às normas e usos honestos do comércio. A primeira hipótese (Pingo Doce/Continente) ilustra, assim, uma actividade lícita; a segunda (Mafarricos/BeautyLab), uma actividade ilícita.

Segundo, no plano teleológico. A publicidade comparativa, quando observada nos termos do art. 16.º, n.º 2 CP, tem como finalidade típica *informar o consumidor*, permitindo-lhe decisões de consumo mais esclarecidas, num quadro de concorrência baseada no mérito. Na primeira hipótese, a Pingo Doce identifica abertamente o concorrente Continente para que o consumidor possa, por si próprio, aferir o diferencial de preços e tomar uma decisão informada. A concorrência desleal, em contrapartida, não tem por finalidade a informação do consumidor, mas o *prejuízo do concorrente*, através da confusão, do descrédito ou do parasitismo da reputação alheia. Na segunda hipótese, a Mafarricos não procura informar quem quer que seja: procura, isso sim, capturar clientela da BeautyLab por via da imitação do *trade dress* (al. a)), da denegrição do produto concorrente (al. b)) e da apropriação parasitária do “capital reputacional” acumulado por mais de um século (al. c)).

Terceiro, no plano dos bens jurídicos tutelados. A publicidade comparativa rege-se, primariamente, pelo CP e pelo RJPCD, cujos bens jurídicos tutelados são, em primeira linha, os interesses dos consumidores (verdade da informação, não-distorção da decisão de transacção) e, indirectamente, a leal concorrência. A concorrência desleal, regulada nos arts. 311.º e 330.º CPI, tutela primariamente a *lealdade do mercado* e os interesses dos *concorrentes*, sem prejuízo da protecção mediata dos consumidores.

O critério que verdadeiramente separa as duas hipóteses sintetiza-se assim: na primeira, a comparação é *método* e a finalidade é a *informação verdadeira*, pelo que basta cumprir os requisitos do art. 16.º, n.º 2 CP para que a peça seja lícita. Na segunda, a aparente "comparação" entre o "Beauty Plus" e o "BeautyLab Original" é, em rigor, um *pretexto* para a confusão, o descrédito e o parasitismo: a Mafarricos não compara objectivamente uma característica essencial (al. c) do art. 16.º, n.º 2), antes denigre o concorrente com falsidades (al. e)), gera confusão pelo packaging (al. d)) e retira partido indevido do renome alheio (al. g)). Caso se quisesse subsumi-la ao art. 16.º CP, falaria logo na al. a) (enganosa, à luz do art. 11.º CP) e na al. e) (desacreditar/depreciar), bastando o incumprimento de uma alínea para excluir a publicidade do espectro do *consentido*. Ora, o que sobeja, depois de excluído o regime da publicidade comparativa, é precisamente o tipo da concorrência desleal, confirmando-se, na prática, a relação de complementaridade entre os dois institutos. Refira-se, finalmente, que os dois regimes podem aplicar-se em concurso. Uma publicidade comparativa que viole, designadamente, as alíneas a), e) ou g) do art. 16.º, n.º 2 CP é simultaneamente publicidade comparativa ilícita (sancionada nos termos do art. 34.º CP) e acto de concorrência desleal (sancionado nos termos do art. 330.º CPI). A própria doutrina⁵⁹ sustenta esta articulação: "*ainda que não haja qualquer violação de direito exclusivo, poderá ocorrer um ilícito publicitário*", e a regulação da actividade publicitária permite qualificar como ilícitos certos actos de aproveitamento de imateriais, independentemente da sua avaliação no plano da Propriedade Industrial.

Em síntese, a primeira hipótese ilustra publicidade comparativa lícita: comparação objectiva, verídica e informativa entre concorrentes identificados, conforme aos requisitos cumulativos do art. 16.º, n.º 2 CP. A segunda ilustra concorrência desleal: confusão, descrédito e parasitismo, contrários às normas e usos honestos do comércio, subsumíveis à cláusula geral do art. 311.º CPI. A primeira é actividade lícita e desejável, sancionada apenas se desrespeitar as condições da licitude. A segunda é actividade *per se* ilícita, sancionada pela própria desconformidade ao padrão ético do "comerciante médio honesto e razoável".

⁵⁹ NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal...*, op. cit., p. 356, capítulo "Fenómenos de Aproveitamento e Publicidade"